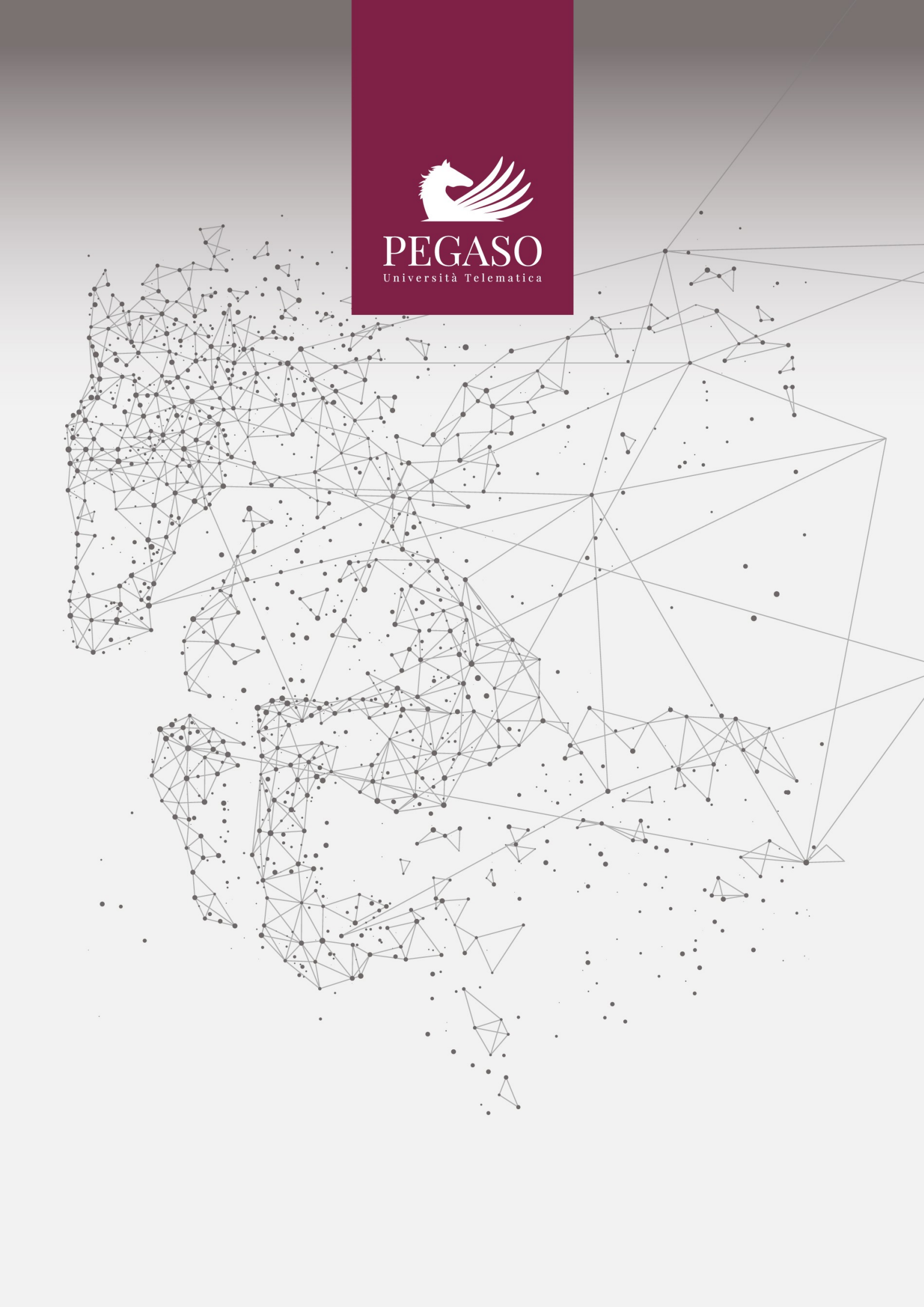

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA CD. "SUCCESSIONE DIGITALE" **3**
2. LA TUTELA DEI DATI DIGITALI DOPO IL DECESSO DEL TITOLARE **6**
3. CONCLUSIONI **10**
BIBLIOGRAFIA **12**

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La cd. "successione digitale"

La rivoluzione digitale ha profondamente cambiato le modalità mediante le quali l'individuo si interfaccia con la realtà e interagisce con i suoi simili. In particolare, oggi si assiste ad una progressiva ed inarrestabile dematerializzazione nel compimento degli atti e delle attività in tutti i settori della vita umana.

Nel contesto della società informatica, pertanto, lo stesso concetto di *privacy* ha finito per evolvere approdando ad una nozione ampia e sostanzialistica nella qualificazione della identità personale. In altre parole, se fino agli anni settanta del '900 l'identità personale rappresentava un insieme di elementi e dati esterni al soggetto, idonei a descriverlo (il nome, la cittadinanza, il sesso ecc.), nel nuovo contesto dematerializzato la nozione si estende a tutti quegli aspetti in grado di descrivere la sua identità nei diversi contesti della propria vita. Dunque, si impone un'accezione ampia di dato personale che tenga conto non solo del "dato" inequivocabilmente qualificabile come tale, ma anche delle ulteriori informazioni che assumono rilevanza per la individuazione dell'identità dell'individuo in rete. Tra queste certamente non potranno non includersi, ad esempio, tutte quelle attività e quei contenuti afferenti alla gestione dei *social networks* o della corrispondenza elettronica: spesso, infatti, non è facile distinguere nell'ambito di tali contenuti ciò che consente di identificare in maniera univoca una persona, e conseguentemente risulti suscettibile di essere ricompreso nella nozione di "dato personale", rispetto a quanto è privo di tale natura.

Deve, peraltro, considerarsi che la massa di informazioni e di dati che ciascun individuo, mediante le tecnologie, immette quotidianamente in rete, è destinata ad essere custodita nella realtà virtuale per un tempo generalmente indefinito, un tempo che può andare anche oltre la vita del soggetto fisico cui risulta riferibile. Ciò determina l'opportunità di controllare i confini della identità durante la vita dell'individuo, nonché di preservarne la memoria per il tempo successivo alla morte, interrogandosi in merito alla sorte di tale moltitudine di dati e alla possibilità di veicolarne la circolazione e il trattamento in seguito al decesso della persona fisica. Invero, il

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

considerando n. 39 del reg. UE 679/2016 sancisce in merito alla durata del trattamento che "I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica". Tuttavia, non è sempre agevole per i titolari di servizi digitali individuare e garantire tale durata, sia per la tendenziale longevità di alcune attività svolte sulle piattaforme digitali – talvolta corrispondenti all'intera vita umana – sia per la concreta impossibilità per i gestori della rete (cdd. *providers*) di controllare l'effettivo periodo di attività in rete da parte di ciascun individuo.

Il tema si fa particolarmente interessante se si pensa alla cd. morte digitale e alle questioni ad essa connesse. Sempre maggiori, infatti, risultano le istanze avanzate da familiari e congiunti per controllare e accedere ai profili degli utenti defunti, ai loro dati, alla loro corrispondenza, alle immagini e contenuti inediti[1]. Rispetto a tali istanze il legislatore non è ancora in grado di offrire risposte adeguate e soddisfacenti. Qui vengono in rilievo due contrapposte esigenze che richiedono un delicato bilanciamento: da un lato, c'è l'interesse dei familiari o congiunti ad accedere e gestire tali dati e contenuti, dall'altro, quello del defunto di mantenere riservate tutte o solo talune informazioni personali.

I profili che vengono in rilievo concernono la protezione ed il trattamento dei dati dell'individuo deceduto, da un lato, e la trasmissione a causa di morte dei beni digitali, dall'altro. Benchè si tratti di distinte questioni, non a torto vengono spesso ricondotte nell'ambito del fenomeno della cd. successione digitale o eredità digitale, espressioni con le quali si fa riferimento alla più ampia problematica della sorte dei cd. *digital asset*, cioè beni immateriali con riferimento ai quali vi è interesse alla trasmissione, per il tempo successivo alla morte. Ed in effetti non si può

[1] Il problema è reale se si pensa che secondo una recente stima, *Facebook*, il più diffuso *social network* al mondo, prima della fine del secolo sarà popolato da più account commemorativi che da profili riferibili ad utenti viventi.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

negare la profonda connessione tra tutela dei diritti della personalità e pianificazione ereditaria soprattutto nella misura in cui quest'ultima assume connotati non più limitati alla sfera patrimoniale dell'individuo, ma riferibili a tutti quegli interessi, informazioni, diritti che possono incidere sulla sfera personale del singolo e che lo connotano nella sua vita di relazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La tutela dei dati digitali dopo il decesso del titolare

Nell'ampia accezione di *privacy* - intesa come una esigenza di controllo da parte dell'individuo non soltanto delle informazioni ad esso relative, ma di tutte le rappresentazioni sociali "reali" e "virtuali" della propria persona che da queste derivano – va ricondotta anche la cd. *privacy post-mortem*. Questa può essere definita come "il diritto del soggetto a preservare e controllare cosa sarà della propria reputazione, dignità, integrità, dei propri segreti e memorie dopo la morte"[2]. Sul punto la legislazione è alquanto scarna.

La direttiva CE del 1995, poi abrogata dal GDPR del 2016, escludeva espressamente il riferimento alle persone decedute, rivolgendosi esclusivamente alle cdd. "natural persons".

Un timido passo in avanti si compie con il Reg. UE 679/2016 che, in merito al trattamento dati dei defunti, al considerando n. 27, si limita a stabilire che la normativa non si applica ai dati personali dei soggetti deceduti, ma lascia spazio agli Stati membri di prevedere una regolazione di dettaglio sul tema.

Il legislatore italiano ha, invero, provveduto ad implementare la disciplina della *privacy post-mortem* introducendo, con il d.lgs. n. 101 del 2018, l'art. 2-*terdecies* nel Codice privacy (d.lgs. n. 196 del 2003). Tale norma, espressamente dedicata ai diritti delle persone decedute, prevede (riprendendo quanto già stabilito dal d.lgs. n. 196 del 2003) la possibilità che i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR (diritto di accesso, rettifica, diritto all'oblio) relativi a persone decedute siano esercitati da chi abbia un interesse proprio, o agisca a tutela dell'interessato (ad es. per interessi familiari).

Tuttavia, vi sono tipologie di dati che non possono essere gestiti, amministrati e consultati dagli eredi del defunto. Invero, stante il fatto che ogni utente del web, purché maggiorenne e dotato della capacità di intendere e di volere, ha il diritto di esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e sanitarie, si possono configurare circostanze a fronte delle quali agli eredi può

[2] L. EDWARDS e E. HARBINJA, *Protecting post-mortem privacy: reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital world*, in *Cardozo Arts & Entertainment*, 2013, p. 101 s.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

essere negato l'accesso a tale particolare categoria di dato sensibile. Motivo per cui, il secondo comma dell'art. 2-*terdecies* del Codice della Privacy introduce un duplice limite alla possibilità di esercizio *post mortem* dei diritti dell'interessato, disponendo che l'esercizio dei diritti di cui al primo capoverso non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata. Previsione, questa, che costituisce l'espressione di una scelta di politica legislativa adottata nell'ottica della massima tutela dei diritti alla dignità e dell'autodeterminazione del singolo individuo, riponendo in capo a quest'ultimo la scelta se lasciare agli eredi legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali oppure impedire l'accesso dei terzi a tali informazioni.

In particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2-*terdecies* consentono all'interessato di vietare a terzi l'esercizio dei diritti suddetti mediante dichiarazione scritta presentata o comunicata al titolare del trattamento dei dati personali prima della morte. Quanto alla natura giuridica di questa dichiarazione, essa può essere considerata come una manifestazione di ultima volontà a contenuto non patrimoniale mediante la quale l'interessato dispone di un proprio interesse personale per il tempo successivo al decesso, precludendo ai terzi l'esercizio dei diritti di acceso, aggiornamento, cancellazione ecc. dei dati personali.

È dato, tuttavia, dubitare della concreta utilità e reale innovatività di questa previsione. Essa infatti si limita a prevedere una dichiarazione inibitoria, e cioè la possibilità di vietare l'esercizio delle azioni e dei diritti previsti dagli artt. 15 ss. GDPR, ma non consente all'interessato di disporre in maniera differente.

Più utile sarebbe stata una previsione dalla portata più ampia che riconoscesse il diritto in capo all'interessato di predeterminare anche quali e quanti dati rendere accessibili a terzi, oppure prevederne la automatica cancellazione o modifica al sopraggiungere del decesso. Nel silenzio della norma, spetterà all'interprete individuare fino a che punto le concrete facoltà dispositive dell'interessato si possano spingere per poter gestire in piena autonomia le informazioni e i dati immessi nella rete dopo la sua morte.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Invero, già alcuni *service provider* riconoscono una maggiore autonomia e prevedono formule tese ad attribuire una più ampia libertà dispositiva in capo all'interessato. In particolare, si segnala che *Google* permette ai propri utenti di disporre della sorte dei propri *accounts* per il tempo in cui avranno cessato di vivere, mediante la configurazione del cd. "*Inactive Accaunt Manager*": si tratta di un programma di gestione dell'*account* inattivo che si azionerà in seguito ad un periodo di *time-out* decorrente dalla data dell'ultimo accesso. Il titolare dell'*account* può determinarne preventivamente la sorte allo scadere di tale arco temporale e scegliere tra la sua eliminazione ovvero la nomina di un "contatto di fiducia" che, decorso il periodo che determina l'inattività, riceverà una notifica con l'eventuale indicazione dei contenuti che il soggetto deceduto ha deciso di condividere con lo stesso.

Anche il *social network Facebook* ha adottato una *policy* simile. In particolare il *provider* offre all'utente tre differenti opzioni: innanzitutto, si può scegliere di rendere il proprio profilo meramente commemorativo, consentendo a parenti ed amici di condividere in esso ricordi.

L'utente può, in alternativa, optare per l'eliminazione dell'account in modo permanente in seguito al decesso.

Infine, è prevista la possibilità di nominare un contatto erede che potrà gestire l'account reso commemorativo, ma non potrà accedere ad esso, né ai relativi contenuti.

Il limite degli strumenti appena richiamati risiede, tuttavia, nella loro immodificabilità: l'utente, infatti, può solo compilare un modello predisposto dal gestore del servizio, ma non può modificare la propria volontà.

Si rende pertanto necessario un intervento del legislatore per regolamentare la pianificazione successoria degli interessi digitali in uno con l'esigenza di salvaguardare la *privacy* degli utenti della rete.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sono diverse le modalità attraverso le quali è possibile manifestare in concreto le volontà dispositive del *de cuius*. Innanzitutto non è necessario, salvo ipotesi particolari[3], rispettare il formalismo richiesto per la redazione di una scheda testamentaria.

Un primo strumento utile per disporre dei contenuti digitali *post mortem* è rappresentato dal mandato *post mortem*, mediante il quale il disponente (mandante) affida ad un altro soggetto (mandatario) un incarico da eseguirsi successivamente al suo decesso. Tale incarico può riguardare l'esecuzione di attività meramente materiali, quali l'eliminazione di alcuni contenuti digitali (es. fotografie) immessi in rete ovvero la cancellazione di determinati *account* ai quali il disponente vuole impedire l'accesso. Il ricorso a tale figura pare essere suggerito dallo stesso legislatore il quale nell'art. 2-*terdecies* cit., nell'individuare i soggetti legittimati ad esercitare i diritti riferiti ai dati delle persone decedute, annovera espressamente anche il mandatario.

Altro strumento utilizzabile è la nomina, nel testamento, di un esecutore testamentario, ai sensi dell'art. 700 c.c., al quale affidare uno o più compiti da eseguirsi in seguito all'apertura della successione.

Negli ultimi anni sono molto diffusi nella prassi servizi di rete che propongono delle soluzioni alternative nella gestione dei *digital assets post mortem*. Nello specifico, talune piattaforme digitali finalizzate principalmente a fornire all'utente un servizio di memorizzazione, aggiornamento e generazione di *password* sicure sul *web*, hanno provveduto a mettere a disposizione del fruitore un ulteriore servizio di devoluzione delle credenziali di accesso in caso di morte dell'utente, in tal modo consentendo una pianificazione ereditaria dei propri interessi relativamente a beni e *account* digitali.

[3] Se, ad esempio, il programma dispositivo cela finalità attributive di beni e interessi suscettibili di una valutazione economica, ancorchè indiretta.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Conclusioni

La difficoltà di regolamentare in maniera compiuta ed esaustiva la materia in esame è accentuata dalla considerazione che la protezione dei dati e dei contenuti digitali in seguito al decesso del titolare è una tematica che involge aspetti assai differenti tra loro, coinvolgendo spesso non solo i profili esistenziali, ma altresì gli interessi patrimoniali dell'interessato. La attuale disciplina contenuta nell'art. 2-*terdecies*, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003, non pare sufficiente in quanto contiene una regolamentazione limitata ad un contenuto meramente negativo. Così come pure insufficienti sono le eventuali condizioni di servizio stabilite da taluni gestori dei servizi digitali.

Per tali ragioni risulta auspicabile una disciplina dettagliata sulla sorte dei propri interessi digitali volta a consentire al soggetto, ancorchè deceduto, di mantenere una forma di controllo, mediante le disposizioni fornite in vita, circa la propria rappresentazione sociale, la propria memoria e reputazione virtuale dopo la morte. Del resto, l'esigenza di tutela della dignità della persona, quale obiettivo che informa tutta la normativa europea in materia di *privacy*, non pare possa venir meno con la morte dell'individuo, tanto più nell'era delle tecnologie dell'informazione, ove anche dopo la morte continua a percepirsi l'esistenza della identità digitale di ciascun uomo. Identità che, pertanto, merita di essere tutelata prima ancora che per una esigenza di ordina giuridico, per una esigenza morale, che trova fondamento nel principio di salvaguardia della dignità umana.

Il tema è stato affrontato in diverse occasioni dalla giurisprudenza. Si segnala, in particolare, una sentenza del tribunale civile di Milano che si è occupato della questione a seguito di un ricorso proposto dai genitori di un minore, defunto in un incidente stradale. I genitori chiedevano l'accesso dei dati del figlio (video, foto) conservati sul cloud di Apple, poiché lo smartphone era rimasto distrutto nello scontro fatale, per cercare di colmare almeno in parte la perdita. Apple rifiutava l'accesso invocando la protezione dell'identità di terzi in contatto col ragazzo, nonché la sicurezza

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dei clienti. Per fornire i dati pretendeva che i genitori divenissero "agenti" del defunto e portatori formali di un "consenso legittimo", in base all'Electronic Communications Privacy Act americano.

Il 10 febbraio 2021, il tribunale di Milano, in via cautelare, ha ordinato a Apple di fornire i dati, ritenendo del tutto illegittima la pretesa di Apple, in quanto subordinerebbe un diritto riconosciuto dall'ordinamento italiano alla previsione di requisiti previsti da norme americane. Il nostro legislatore, invece, nell'art.2-terdecies del Codice Privacy demanda alla persona la scelta in vita se lasciare o meno agli eredi la facoltà di accedere ai propri dati; pertanto, in assenza di un espresso divieto attribuisce agli eredi, o a chi agisca per "ragioni familiari meritevoli di protezione", il diritto ad esercitare i diritti del defunto. Peraltro, il Tribunale di Milano rileva che la richiesta dei genitori concerne esclusivamente dati non afferenti allo stato di salute del figlio deceduto o per i quali questi abbia espresso un diniego di accesso e ritiene sussistente una fondata ragione familiare meritevole di protezione, tenuto altresì conto del pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile all'esercizio dei diritti connessi ai dati personali, in virtù del fatto che dopo un periodo di inattività dell'account cloud le foto ed i video sarebbero stati automaticamente distrutti. Pertanto, i giudici riconoscono il diritto di accesso ai genitori, ritenendo che lo stesso prevalga sulla sicurezza dei clienti opposta da Apple, e condannano la società a fornire le chiavi di accesso.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Il materiale della lezione è stato tratto dal seguente Autore, al quale si rinvia per i dovuti approfondimenti:
- Sasso, *Privacy post-mortem e "successione digitale"*, in *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, a cura di E. Tosi, Milano, 2019, p. 553 ss.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).